

1500268-26.2019.8.26.0612

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANA DEL COMPARI MAIA DA CUNHA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... já decidiu o E. TJSP em caso análogo:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelação que se limita a questionar a aplicação da causa especial de aumento de pena referente à participação da adolescente.

Impossibilidade. Apelante que confessa o tráfico, mas nega conhecer a menor. Fala dos policiais sobre o momento da abordagem que não dá margem para dúvida acerca da atuação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

3ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, Taquaritinga-SP - cep 15900-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500268-26.2019.8.26.0612 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500268-26.2019.8.26.0612

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FERNANDO MARIA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANA DEL COMPARI MAIA DA CUNHA

LUIS FERNANDO MARIA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos à pág. 08, foi DENUNCIADO como incurso no artigo 33, "caput" c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra a Denúncia que, no dia 22 de dezembro de 2019, por volta de 22h00min, na Rua Otávio dos Santos Cavalheiros, nº 261, Bairro Vila de Santi, nesta cidade e comarca, o acusado, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente Richard Henrique Gomes Neves, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 05 (cinco) pedras de "crack", com peso líquido de 0,91 gramas e 01 (uma) porção de "crack", a granel, com peso líquido de 7,42 gramas, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 14/15 e laudos toxicológicos a fls. 73/75 e 76/78.

Segundo o apurado, a Polícia Militar recebeu informação via 190 de que o acusado e Richard estavam comercializando drogas no local dos fatos.

Os policiais foram até o local indicado e avistaram o adolescente defronte ao imóvel. Ao perceber a presença dos agentes públicos, Richard entrou na residência e

foi seguido pelos milicianos que surpreenderam o acusado sentado em um dos cômodos, embalando as pedras de "crack", com o uso de uma faca. Foram apreendidas cinco pedras de "crack" já embaladas e o restante da droga foi encontrado dentro de um prato.

Na ocasião, ambos admitiram que estavam vendendo cada porção da droga por R\$ 10,00. Prosseguindo com as diligências, os policiais apreenderam R\$ 168,80 proveniente do comércio ilegal de entorpecentes e os sacos plásticos que estavam sendo usados na confecção das embalagens.

O contexto da prisão, a razoável quantidade de droga apreendida, a confissão dos envolvidos, bem como o dinheiro e demais insumos encontrados, revelam o envolvimento deles com o narcotráfico.

O Réu negou a prática da infração penal. (p. 08)

O acusado preso em flagrante foi posto em liberdade provisória com medidas cautelares, após audiência de custódia. (p. 46/48)

Recebida a Denúncia em 11 de Fevereiro de 2020.

O Ministério Público requereu a prisão preventiva do acusado após tentativa de citação infrutífera, o qual foi indeferido nos termos da Decisão às págs. 135/136. Posteriormente, o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação às págs. 166/169.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas. Em seguida, o réu foi interrogado. Por fim, O Ministério Público e a Defesa apresentaram suas alegações finais.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, não há nulidade em relação à busca domiciliar. Não se desconhece o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quanto à prova de autorização do morador para a entrada da polícia, especialmente nos crimes de tráfico de drogas quando não há mandado judicial (HC 598.051 e 616.584 - julgados de março de 2021). Entretanto, os aludidos julgados foram proferidos em março de 2021 e os fatos aqui narrados em dezembro de 2019. A decisão do HC 598.051, inclusive, fixou prazo de 1 (um) ano da decisão para que a PM se aparelhe e treine seu efetivo para as novas diretrizes.

Ademais, os mesmos julgados, os quais - frise-se - são posteriores aos fatos, ressaltam as situações em que havendo "suspeita de crime em flagrante", existam fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No presente caso, o adolescente que já era conhecido no meio policial, ao ser abordado, correu para a residência. A continuidade de diligência dos policiais, com a entrada no imóvel, aconteceu, pois a denúncia anônima foi parcialmente confirmada com a fuga do adolescente. Ao entrar no imóvel constatou a presença do acusado embalando o entorpecente, confirmando as denúncias anônimas recebidas de que o adolescente junto ao acusado estaria praticando a narcotraficância. Segundo o C. STF, ao julgar o RE 603.616, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em razões concretas, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito.

A ação é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante às págs. 01/02, Boletim de Ocorrência às págs. 10/13, auto de exibição e apreensão à pág. 14/15, fotografias às págs. 16/23, auto de constatação preliminar às págs. 24, laudo pericial do exame químico-toxicológico às págs. 73/75 às págs. 76/78, laudo descritivo de objeto às págs. 79/82, 83/86, e às págs. 102/105, relatório final às págs. 87/89, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também foi comprovada.

A testemunha Policial Militar Leandro Ângelo Moreira, em sede policial, às págs. 03/04, relatou "Que na data de hoje se encontrava de serviço em companhia do CABO SERAPIÃO, quando recebeu denuncia via 190, dando conta de no local dos fatos havia dois indivíduos, conhecidos por LUIS e RICHARD e que eles estariam lá vendendo drogas. Que se dirigiram para o local e o RICHARD já conhecido dos meios policiais,

se encontrava em frente a casa constante da denuncia. Que quando foram proceder a abordagem do mesmo, ele correu para o interior da casa, deixando o portão que dá acesso para a rua aberto. Que o depoente e seu parceiro adentraram ao local, tendo em vista a denuncia, e ao olhar para a esquerda avistaram RICHARD em pé em frente a porta de um dos cômodos, existente no terreno e o ora autuado, LUIS FERNANDO, sentado, na posse das drogas que foram apreendidas, parte delas já embaladas e parte ele estava embalando, pois as pedras ainda estavam em um prato. Que foi feita busca pessoal em ambos e com eles nada foi encontrado, contudo, no interior da casa, além da droga foram encontrados plásticos utilizados para embalar a droga e a importância de R\$ 168,80 (Cento e sessenta e oito Reais e oitenta centavos) em notas variadas e pássaros, dois canários da terra e três coleirinhas, o quais também foram apreendidos entregues à senhora GABRIELA namorada de LUIS que não se encontrava no local no momento dos fatos, para quem os pássaros foram entregues, mediante auto de depósito, sendo que segundo contato feita com a Policia Florestal de Jaboticabal, tais pássaros serão buscados ainda nesta semana. Que indagados sobre a droga os dois declararam que estavam vendendo crack, cada pedra por R\$ 10,00 (Dez Reais). Que já nesta Delegacia, apesar de RICHARD alegar que tinha 18 anos, ficou constatado que ele nasceu 15/02/2003, portanto tem apenas 16 anos, tendo a senhora sua mãe sido comunicada e comparecido à Delegacia, onde confirmou a idade do filho, bem como foi realizada pesquisa do RG CIVIL do mesmo junto a Prodesp, se comprovou que RICHARD é adolescente. Que em face do constatado, foi dada voz de prisão ao autuado LUIS FERNANDO, tendo a autoridade, diante das circunstâncias dos fatos, determinado a lavratura de Auto de Prisão em Flagrante". Em juízo, disse que a denúncia já informava o nome dos dois envolvidos. Luis Fernando estava embalando o crack. O dinheiro estava dentro de mochila escolar. Richard mentiu ser maior de idade. Os dois assumiram que estariam vendendo as drogas, cada pedra por R\$ 10,00. A casa não tinha móveis e estavam usando velas para iluminar o local. Richard estava sozinho bem próximo à casa.

A testemunha Policial Militar Edson Serapião Ribeiro Junior, em sede policial, à pág. 05, relatou "Que na data de hoje se encontrava de serviço juntamente com o CABO MOREIRA, quando foram acionados via CAD, dando conta de denuncia através dos 190, noticiando que no local dos fatos, dois elementos de nome RICHARD e LUIS estariam traficando drogas. Que se deslocaram para verificar a procedência da denuncia, até o local indicado, sendo que ao chegarem, já avistaram RICHARD, que é conhecido dos meios policiais por envolvimento com drogas, o qual ao perceber a presença da viatura, adentrou ao quintal da residência, deixando o portão aberto. Que entraram no quintal da casa no sentido de proceder a abordagem do mesmo, momento em que viram RICHARD na porta de um dos cômodos e LUIS FERNANDO, dentro do cômodo, agachado embalando as pedras de crack, sendo que cinco pedras já embaladas e o resto ainda sem embalar dentro de um prato, totalizando 15 gramas. Que foi realizada revista pessoal nos dois e com eles nada foi encontrado. Que indagado a ambos a respeito da droga que estava com eles, no interior da casa, os dois confessaram que eles estavam vendendo cada pedra por R\$ 10,00 (Dez Reais). Que no chão ao lado da droga encontrada a importância de R\$ 168,80 (Cento e Sessenta e oito Reais e oitenta centavos). Que na casa também havia dois canários da terra e três colerinhas as quais foram apreendidas e entregues, mediante Auto de Deposito a GABRIELA, namorada de LUIS, sendo que a Policia Ambiental foi acionada e virá buscar os pássaros ainda nesta semana. Que conduzidos a Delegacia foi verificado que RICHARD o qual afirmava que era maior de idade, mas não possuía documentos, se tratava de adolescente com 16 anos de idade, momento que em foi acionada a senhora sua mãe, através do Conselho Tutelar, sendo que procedida pesquisa junto a Prodesp se comprovou que realmente ele é adolescente. Que foi dada voz de prisão a LUIS FERNANDO, tendo a autoridade após tomar ciência dos fatos e suas circunstâncias, determinado a lavratura de Auto de Prisão em Flagrante. Nada mais disse nem lhe foi perguntado."

Em juízo, disse que a denúncia já indicava o nome dos dois envolvidos. Era uma residência curta de dois ou 3 cômodos. Eles empacotavam as drogas. Luis Fernando embalava as pedras de crack, agachado. Havia mais de 30 pedras de crack. Richard disse ser maior na abordagem. Já conhecia Richard, que sempre deu trabalho para a

polícia. Hoje, Richard é maior e morador de rua. Luis Fernando não tinha feito ocorrências ainda, embora já tivesse ouvido falar. Luis Fernando nada disse, pedindo apenas para a namorada ficar com os passarinhos dele. A residência não tinha camas, embalavam à luz de velas. Tinha portas e janelas, mas não tinha móveis. Ratificou declarações da fase policial.

Interrogado o Réu Luis Fernando Maria de Oliveira, em sede policial, às págs. 08, relatou "QUE sua família está ciente de sua prisão, estando presente nesta Delegacia no momento da lavratura do auto a sua convivente GABRIELA FERNANDA BARBOSA; Que não tem filhos; Que não possui advogado, tendo sido informado que copia deste será encaminhada à Defensoria Pública. OA INTERROGATORIO, negou a prática do delito, alegando que a droga, crack, não era dele, que ele não iria vender, que não estava traficando e que não estava agaichado embalando as pedras de crack quando os policiais chegaram. Que as pedras eram de RICHARD. Nada mais disse nem lhe foi perguntado."

Em juízo, disse que tem um filho nascido ano passado. Nunca teve passagens na infância. Trabalha carregando lenha e agora está fixo como servente. Mora sozinho pagando aluguel com sua esposa. Nega ter envolvimento com a droga. Disse que estava dormindo no local. A casa era sua, era ele quem pagava o aluguel. Tinha um fogão, um guarda-roupa e seu colchão e uma estante simples. É primo de Richard. A família não gostava de Richard, então deixava ele ficar lá quando não tinha para onde ir. Sabia que Richard era usuário, mas não sabia que ele vendia. Fazia uns 3 dias que ele estava dormindo lá quando foram abordados. É mentira que estava embalando drogas. Não sabia que Richard estava levando droga para lá. Está respondendo a outro processo

Nota-se, portanto, que ao final da instrução, temos que os fatos descritos na denúncia foram comprovados.

Sabe-se que o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Não se pode perder de vista que, para a prática de tráfico, não é necessária atividade estrita de mercancia, mas tão somente a realização de uma das ações especificadas no mencionado dispositivo, a saber.

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar" (grifei)

"O crime de tráfico de drogas consuma-se pela prática de qualquer uma das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/06, assim, considera-se típica não apenas a venda, mas também o depósito e a guarda do entorpecentes, hipótese dos autos." (STJ, Quinta Turma, HC 210.746/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, j. em 26/06/2012, DJe de 01/08/2012).

No caso, tem-se que a conduta do réu de embalar os entorpecentes para venda no interior da residência está prevista no tipo penal em comento.

As testemunhas policiais militares confirmaram em juízo a apreensão da droga; Os Policiais receberam a informação via 190 de que no local dos fatos havia dois indivíduos vendendo drogas. As denúncias indicavam o nome do maior e do adolescente.

Ao chegar ao endereço indicado, constatou-se a presença do adolescente Richard defronte ao imóvel, o qual, ao perceber a iminência da abordagem policial, correu para o interior do imóvel deixando o portão aberto.

Em continuidade às diligências, os policiais adentraram ao imóvel e constataram a presença do acusado que estava em um cômodo agachado embalando as drogas, sendo que cinco pedras de "Crack" já estavam embaladas. (p. 16). Leandro Moreira afirmou em juízo que ambos confessaram informalmente a prática delitativa, efetuando a venda por R\$ 10,00 a pedra.

Na ocasião, foram apreendidas cinco pedras de cracks acondicionadas em invólucro plástico e 10,59 gramas brutas de crack acondicionadas em um único invólucro plástico, um prato de vidro, com resquícios de "Crack", uma faca de cozinha, com resquícios de Crack, 30 sacos plásticos transparente, e R\$ 168,80 em moedas e cédulas variadas.

As cinco pedras de "Crack" atestaram positivo para substância entorpecente "COCAÍNA", na quantidade de 5,33 gramas (brutas) e 0,91 gramas (líquida); em relação às 10,59 gramas apreendida acondicionadas em 1 invólucro plástico, também, atestaram positivo para substância entorpecente "COCAÍNA" na quantidade de 10,59 gramas (bruta) e 7,42 gramas (líquida), conforme laudos periciais de exame químico toxicológico, respectivamente, às págs. 73/75 e 76/78.

Em relação à faca e ao prato apreendidos foram constatados por laudo pericial a substância "Cocaína" (p. 83/86 e p. 102/105).

Veja-se, ainda, que foram apreendidos 30 (trinta) sacos plásticos de alta densidade, encontrados no interior da residência, material comumente utilizado para o embalamento e comercialização de entorpecentes (p. 79/82).

Os policiais militares, ainda, afirmaram que a casa não tinha luz e pouquíssimos cômodos. Luiz afirma estar morando no local, pagando aluguel, e que Richard estava há 3 dias na sua casa. É seu primo e sabe que sua família não gosta muito dele, então permite que ele ali se instale quando preciso.

Os entorpecentes, objetos e o montante de dinheiro fracionado apontam para a ocorrência do crime previsto no caput do art. 33 da lei 11.343/2006, estivessem eles morando ali ou não.

Os policiais foram enfáticos ao afirmar que o acusado estava embalando o entorpecente para comercialização.

Com efeito, seguros e coesos são os depoimentos dos agentes militares que estão, inclusive, alinhados aos demais elementos trazidos aos autos, não havendo indícios, ainda que mínimos, de que tenham tentado gratuitamente incriminar o acusado.

Vale deixar consignado que o depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho, como já assentado pacificamente pela doutrina e jurisprudência, a não ser que haja motivos concretos para suspeitar de sua veracidade, o que não ocorre na hipótese. Ademais, as declarações de agentes públicos têm fé pública, cabendo à parte que alega provar o contrário. Sem contar que prestam compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.

A propósito já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal no sentido de que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, ao decidir que: "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO, p. 189).

Neste sentido, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em caso análogo:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA DOSIMETRIA DAS PENAS - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - REDUÇÃO DA BÁSICA AO MÍNIMO LEGAL PORQUANTO A NOCIVIDADE DA DROGA É ELEMENTAR DO TIPO PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1500612-36.2018.8.26.0452; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piraju - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021, grifou-se).

Incidência do art. 40 VI da Lei de Drogas.

O Art. 40, inciso VI da lei de drogas prevê causa de aumento de pena para as hipóteses em que os crimes previstos nos artigos 33 a 37 da referida lei envolvam criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação.

A doutrina e a jurisprudência ensinam:

"Envolver criança ou adolescente tem o sentido de atuar conjuntamente, utilizar ou contar com a participação. É hipótese em que o agente atua em concurso eventual com criança ou adolescente, aliás, prática recorrente no ambiente do tráfico, notadamente em razão da menor capacidade de discernimento e resistência moral daqueles, a proporcionar maiores facilidade na cooptação, e da condição de inimizabilidade a que os mesmos personagens-alvo estão submetidos." (MARCÃO, Renato, Tóxicos. 4ª, ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 340).

"a previsão feita pela redação do tipo derivado: envolver (trazer menor para cenário das drogas, sob qualquer pretexto) ou visar (ter o menor como meta para uso de drogas). Por isso, o menor pode ser participante ou vítima do tráfico ilícito de entorpecente" (Nucci, Guilherme de Souza - Lei Penais e Processuais penais comentadas / 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pág. 348 - grifou-se).

"Para configuração do crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, basta a participação de menor de 18 anos no cometimento do delito, pois, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o crime é formal e, por isso, independe da prova da efetiva corrupção do menor (Súmula 500/STJ). Por sua vez, para incidir a majorante da Lei de Drogas, faz-se necessário que, ao praticar os delitos previstos nos arts. 33 a 37, o réu envolva ou vise atingir criança, adolescente ou quem tenha capacidade de entendimento e determinação diminuída. Entendo que 'o verbo visar significa ter em mira o menor ou o incapaz para a conquista de mais um usuário, sendo irrelevante que o sujeito-alvo adquira ou consuma a droga. O verbo envolver, que representa inovação legal, demanda a colaboração de menor ou de incapaz no tráfico, de modo que se torne um comparsa do traficante, embora não se exija reiteração na parceria' (GUIMARÃES, Marcello Ovidio Lopes coord. Nova Lei Antidrogas Comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2007, págs. 218/219)" (STJ, Sexta Turma, REsp 1.622.781/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 22/11/2016, DJe de 12/12/2016) (grifei).

Nesse contexto, é prescindível que o adolescente tenha sido influenciado pelo acusado para a prática de tráfico de drogas. Luiz é primo do adolescente e sabia, portanto, da sua menoridade, e também de sua vulnerabilidade maior pelo fato da família não acolher o menor. O PM Edson afirmou em juízo que o menor, hoje, mora nas ruas.

É o suficiente para a incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

O réu será beneficiado pelo redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Nos delitos de tráfico, as penas poderão ser reduzidas desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Na hipótese, verifica-se que o réu é primário (Certidão Criminal às págs. 201/202 e FA às págs. 125) e não possui maus antecedentes.

Ademais, o réu não possui maus antecedentes, tampouco restou demonstrado que se dedique às atividades criminosas e/ou integre organização criminosa.

Com efeito, tratando-se de traficância praticada por agente primário sem maus antecedentes, cabe deferir-lhe a assistência legal máxima do redutor legal específico do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Neste sentido, já decidiu o E. TJSP em caso análogo:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelação que se limita a questionar a aplicação da causa especial de aumento de pena referente à participação da adolescente. Impossibilidade. Apelante que confessa o tráfico, mas nega conhecer a menor. Fala dos policiais sobre o momento da abordagem que não dá margem para dúvida acerca da

atuação conjunta de ambas. Afastamento da majorante referente à proximidade de escolas. Absoluta ausência de demonstração de que visava os frequentadores. Crime praticado em um domingo e em período de férias escolares. Caso de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Apelante de 19 anos, absolutamente primária, confessa e que tinha pequena quantidade de substâncias proscritas (10,3g de cocaína, 27,3g de maconha e 1,6g de crack). Concurso eventual de adolescente insuficiente para caracterizar participação em grupo criminoso. Penas reduzidas a 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mais 221 dias-multa. Regime inicial aberto e substituição das carcerárias por restritivas de direitos. Apelo provido em parte." (TJSP; Apelação Criminal 1500722-13.2018.8.26.0621; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Aparecida - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020, grifou-se) Por fim, atenta ao artigo 42 da Lei de Drogas ("O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente"), entendo não ser o caso de majoração da pena base. Não se ignora a possibilidade do magistrado, em crimes de tráfico de drogas, no momento da dosimetria da pena, aumentar a pena-base com respaldo na natureza e na quantidade de entorpecente apreendido, cumulativamente.

Aqui, a quantidade da droga apreendida (cinco pedras de cracks acondicionadas em invólucro plástico e 10,59 gramas brutas de crack acondicionadas em um único invólucro plástico) é normal para o tráfico da região, e somente foi encontrado este tipo de droga, aspectos que são valorados favoravelmente ao acusado, na primeira fase da dosimetria da pena.

Passo a fixação da pena.

As circunstâncias judiciais são favoráveis, tendo em vista que o réu é primário (folha de antecedentes às págs. 125 e certidões às págs. 201/202). Os motivos não são repugnantes e as consequências não extrapolam a gravidade natural do crime. Fixo, portanto, a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes. A atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, há causa especial de aumento de pena, devendo a pena ser exasperada em 1/6, nos termos do art. 40, inciso, VI, da lei 11.343/2006 por ter sido o ilícito praticado junto com adolescente, perfazendo-se 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, há causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de drogas, a qual aplico no patamar máximo de 2/3 (dois terços). Pena final, portanto, em 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 194 (cento e sessenta e seis) dias-multa, unitariamente no mínimo legal. Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena imposta ao réu, em razão da primariedade e quantidade da pena aplicada, lembrando que o C. STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/90, nos autos do Habeas Corpus nº 111.840/ES, j. 27/06/2012, por afronta ao princípio da individualização das penas. Entendo suficiente e socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez presentes os requisitos (art. 44, CP) e porque declarada a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei de Drogas (HC 97.256 STF, j. 01/09/2010).

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu LUIS FERNANDO MARIA DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput" c.c com o Art. 40, inciso VI ambos da Lei 11.343/06 à pena privativa de liberdade 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10(dez) dias de reclusão e 194 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então. Presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação pecuniária no valor de um (01) salário mínimo; b)

prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da privativa de liberdade. As entidades beneficiárias e a forma da prestação de serviços serão especificadas pelo Juízo das Execuções Criminais.

Havendo descumprimento injustificado da pena restritiva de direito supramencionada, voltará a incidir a pena privativa de liberdade inicialmente fixada.

O réu respondeu ao processo em liberdade e não há fundamento para sua custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), razão pela qual poderá recorrer em liberdade. Com fundamento no artigo 387, § 1º, CPP, mantenho a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, contidas na decisão de p. 46/48, uma vez que o réu mudou de endereço e somente comunicou o juízo após tentativas frustradas de localização pela Serventia (p. 196), intimando-se sua advogada via DJe, a qual, finalmente, informou-o corretamente (p. 197). Alimente-se pelo Projeto V.I.D.A.

O réu é beneficiário da assistência judiciária, estando isento do pagamento de custas. Pedido da defesa que se defere nesta oportunidade.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas que ainda não tenham sido incineradas, oficiando-se.

Com o trânsito em julgado, providencie o cartório, se o caso: A) Extração da tarja vermelha identificadora de réu preso, tendo em vista o trânsito em julgado do V. Acórdão, bem como a atualização dos dados no sistema informatizado; B) as comunicações de praxe (Delpol, IIRGD e TRE); C) guia de recolhimento; D) certidão de honorários.

Por fim, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Taquaritinga, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA